

1500774-81.2020.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500774-81.2020.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500774-81.2020.8.26.0348

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

LUCAS RIBEIRO DA SILVA (R.G. 38.437.789-0) foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, pois, na data de 19 de novembro de 2019, horário incerto, em um escadão, nas proximidades da Rua Rubens Borba Alves de Moraes, nº 152, Jardim Guaianazes, São Paulo, capital, obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de R\$ 3.600,00, em prejuízo de Clenilson dos Santos Costa, induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04. Segundo o apurado, LUCAS, utilizando o nome de "Paulo Gomes", se interessou pelo anúncio no site Mercado Livre realizado pela vítima, de uma máquina de estamparia de camisetas e outra de canecas, ambas da marca Compacta Print, bem como uma impressora sublimática da marca Epson, avaliados em R\$ 3.600,00.

Depois de negociarem através de aplicativo do telefone 11 954862302, "Paulo Gomes" afirmou ter adquirido os objetos através do mercado pago e, para tanto, encaminhou um e-mail com um falso comprovante de pagamento à vítima.

Induzido ao erro, Clenilson acreditou no pagamento e entregou os objetos supostamente adquiridos para o motorista de um carro de aplicativo, de placas FVX 9198, enviado para retirar os objetos. Após a entrega, Clenilson contatou o site Mercado Livre e constatou que o pagamento não tinha sido efetuado e que o e-mail enviado pelo denunciado era falso (fls. 17/19).

A vítima informou o golpe à Polícia Civil e, durante as investigações ficou constatado que a linha telefônica, 11 95486 2302, utilizada pelo suposto "Paulo Gomes" estava cadastrada na operadora TIM em nome do denunciado, CPF nº 496.505.298-61 (fl. 11), cujo endereço era Rua Rubens Borba Alves de Moraes, nº

152, Jardim Guaianazes, São Paulo/SP.

Além disso, o motorista do carro de aplicativo, Naidson, explicou que foi contratado por um indivíduo que se identificou como “Gabriel” para retirar uma encomenda na residência da vítima e lhe entregar no bairro de Guaianazes, São Paulo, e ainda reconheceu fotograficamente o denunciado como sendo o indivíduo que se apresentou como “Gabriel” e recebeu a encomenda no bairro de Guaianazes (fls. 13/14 e 44).

Indagado perante a Autoridade Policial, o denunciado negou o cometimento do crime (fl. 37).

Representação da vítima a fl. 16.

A denúncia foi recebida em 09 de julho de 2020 (fls. 78/79). O réu foi citado (fls. 87). Resposta à acusação (fls. 94). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 95/96). Com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 97 e 99).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. No mesmo sentido a manifestação da defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu LUCAS pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Ao final da instrução criminal, é de rigor reconhecer a IMPROCEDÊNCIA da ação.

Senão vejamos:

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através da prova colacionada aos autos, em especial, do boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de declarações da vítima (fls. 05 e 16), termo de depoimento da testemunha (fls. 06), documentos apresentados pela vítima e pela testemunha (fls. 07/08, 13/14 e 17/19), informações fornecidas pela operadora de telefonia (fls. 09/11), bem como pela farta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação a autoria.

Senão vejamos:

Na fase policial, o réu LUCAS alegou que não tem relação com o crime apurado, nem mesmo conhece tal pessoa que registrou o boletim de ocorrência. Nunca emprestou seus dados para terceiros adquirirem chips de telefonia em seu nome. Desconhece o nº 11.95486.2303, utilizado na transação ilícita, que está cadastrado em seu nome. Não possui telefone celular e apenas tem o de contato o de sua mãe. Sobre o fato de ter sido reconhecido pelo motorista de aplicativo como tendo sido a pessoa que recebeu de suas mãos, os objetos reclamados pela vítima, disse o investigado estranhar tal imputação, já que, como dito anteriormente, nega qualquer envolvimento no crime, nem mesmo imagina a razão pela qual esse motorista tenha o reconhecido por foto (fls. 37).

Em Juízo, o réu LUCAS optou por permanecer em silêncio.

Em que pese a falta de versão do réu em Juízo, o fato é que não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório, acerca da efetiva participação do réu na empreitada criminosa.

A vítima CLENILSON, não foi ouvida, pois não localizada.

A testemunha de acusação NAIDSON, em Juízo, não foi ouvido, pois faleceu.

Embora o réu tenha sido reconhecido por foto pela testemunha na fase policial, o certo é que tal prova não foi ratificada em Juízo, ou seja, não existem provas judicializadas da autoria, fato que impede a prolação de decreto condenatório.

Noto que a proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: “O juiz formará sua convicção pela livre

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009).

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

Neste sentido: "EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação." (STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003).

Sendo assim, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais

a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Pelo exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu LUCAS RIBEIRO DA SILVA (R.G. 38.437.789-0), das sanções do artigo 171 do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA